

RECURSO CÍVEL Nº 5069588-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: EVELYN CRISTINE DE OLIVEIRA ESTEFANE MIRANDA (AUTOR)

MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REFERENTE AO ANOS DE 2016 E 2023. AÇÃO AJUIZADA EM 2024. PRETENSÃO PRESCRITA TÃO SOMENTE QUANTO AO AUXÍLIO PAGO EM 2016. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condene o recorrente vencido em honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se. Após, com as cautelas de praxe, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5069588-97.2024.4.02.5101

510015372984 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5069588-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: EVELYN CRISTINE DE OLIVEIRA ESTEFANE MIRANDA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela União em face da sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a União Federal ao pagamento de R\$ 6.169,00 referente às diferenças de auxílio fardamento devido na promoção a Suboficial, valor a ser corrigido a partir de dezembro de 2023 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da data da citação, tudo conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, até efetivo pagamento. Condene a União ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação, e condene a autora ao pagamento de honorários de sucumbência de R\$ 436,10 (10% sobre o valor das diferenças pretendidas quanto à promoção de 2016).

Sustenta o Recorrente que o termo inicial da contagem da prescrição é a data da ocorrência do pagamento a menor, e, portanto, a questão já estaria prescrita, eis que o mesmo ocorreu em 2016.

VOTO

I - Do Direito:

A Turma Nacional de Uniformização, quando do julgamento do PEDILEF n.º 0507165-55.2018.4.05.8400/RN (tema 212), firmou o entendimento no sentido de ser devido o pagamento integral do auxílio fardamento, no valor de um soldo do novo posto ou graduação, ainda que tenha recebido a mesma vantagem anteriormente dentro do prazo de um ano, sendo ilegal a limitação imposta pelo artigo 31 do Decreto n.º 4.307/2002. Confira-se:

Tema	212	Situação do tema	Julgado	Ramo do direito	DIREITO ADMINISTRATIVO
Questão submetida a julgamento	Saber se o militar promovido no período de até um ano após fazer jus ao auxílio-fardamento, tem direito somente à diferença entre o valor do auxílio referente ao novo posto ou graduação e o efetivamente recebido, nos termos do art. 61, do Decreto nº 4.307/2002.				
Tese firmada	O militar promovido tem direito ao recebimento integral do auxílio-fardamento no valor de um soldo do novo posto ou graduação, mesmo que tenha recebido a mesma vantagem anteriormente dentro do prazo de um ano, sendo ilegal a limitação imposta pelo art. 61 do Decreto n. 4.307/2002.				
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 0507165-55.2018.4.05.8400/RN	23/05/2019	Juiz Federal Paulo Cezar Neves Júnior	25/2/2021	26/2/2021 29/04/2021	RE admitido

Transcrevo trechos do voto vencedor:

"[...]

O recorrente alega, em síntese, que o escopo do auxílio-fardamento era dotar o militar de recursos necessários para a aquisição de uniformes, razão pela qual a utilização dos uniformes deveria se dar num período relativamente longo de tempo.

Sustenta que o artigo 3º, inciso XII, do texto legal acima transcrito conferiu expressamente a prerrogativa da Administração Pública ao exercício de um dos Poderes por ela abarcado, qual seja, o Poder Regulamentar ou, como prefere parte da doutrina, Poder Normativo.

*No entanto, esse Poder Normativo do Poder Executivo tem limites, que assim foram bem sintetizados por Celso Antônio Bandeira de Mello: a) não poderá incluir no ordenamento jurídico regra geradora de direitos ou obrigações novos; **b) caberá à lei indicar as condições para a aquisição de um direito, cabendo ao regulamento apenas a especificação dessas condições**; c) proíbe-se a chamada "delegação disfarçada" de competência legal ao regulamento, o que ocorreria quando a lei diferisse ao regulamento definir por si mesmo as condições ou requisitos necessários ao nascimento do direito material ou da obrigação, dever ou restrição; **d) o regulamento não poderá em hipótese alguma contrariar a lei ou ditar restrições a ela, ainda que a pretexto de esclarecê-la** (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2000, 12ª ed, pp. 307-312).*

Nessa esteira, ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, o condicionamento de tempo estabelecido pelo decreto em tela, não constituiu uma mera regulamentação, mas verdadeira condição para gozo da vantagem ou restrição a ela, que deveria ser prevista em lei.

Assim, a meu ver, o decreto, ao estabelecer limites aos valores de pagamento do auxílio-fardamento acabou por estipular exigência ou impor limitação não prevista em lei. Isso porque, como se viu, a Medida Provisória nº 2.215-10 definiu claramente as condições e os valores para pagamento da verba em questão, não havendo espaço para que norma infralegal viesse limitar o direito tal como definido por aquela norma superior.

Logo, o Poder Executivo extrapolou os limites da legislação violando o princípio da legalidade, tal como reconhecido em situação análoga no julgado abaixo:

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. DECRETO REGULAMENTAR. ESTIPULAÇÃO DE EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

*1. Os atos normativos de natureza administrativa que visam **regulamentar** normas gerais e abstratas têm como função a complementação da disciplina contida em lei strictu sensu, sendo vedado extrapolar os limites da legislação em sede de **decreto regulamentar**, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal.*

Precedentes do STF: AgRg no RE. 583.785, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 22.2.2013; AgRg no RE. 458.735, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 3.2.2006.

(...)

(Processo - AgRg no AREsp 231652 / PR - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2012/0196057-6 - Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133) - Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento 07/03/2017 - Data da Publicação/Fonte DJe 21/03/2017)

Destaco que não se aplica ao caso o entendimento definido no Tema 538 do E. Superior Tribunal de Justiça porque, nesse último, a norma de regência (Lei n. 8.112/90), ao tratar da ajuda de custo, **ao contrário da presente (MP 2.215/2001), não fixou valores, deixando para a regulamentação um espaço maior de atuação**, como se observa do art. 54 daquele Diploma Legal (Lei n. 8.112/90): "A ajuda de custo é calculada /sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 (três) meses".

Portanto, não procedem os argumentos da recorrente.

Análise do Caso Concreto

No presente caso, o acórdão recorrido analisou a questão sob o prisma ora definido, na medida em que decidiu a controvérsia nos seguintes termos:

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento diferenças de auxílio-fardamento. Aduz que o Decreto 4.307/02, em seu artigo 61, que extrapolou o poder regulamentar ao estabelecer limitação ao valor do Auxílio-Fardamento na hipótese de promoção ou enquadramento no período de até um ano após já ter feito jus ao benefício em alusão.

2. A Medida Provisória nº 2.215-10/2001, ao dispor acerca da reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, estabelece em seu art. 2º, inciso I, alínea d, dentre os direitos remuneratórios, o direito ao auxílio-fardamento.

3. O artigo 3º do aludido diploma enuncia que o auxílio-fardamento consiste direito pecuniário devido ao militar para custear gastos com fardamento, conforme regulamentação.

4. Com a edição do Decreto nº 4.307, de 18 de julho de 2002, foi regulamentada a matéria nos seguintes moldes: Art. 61. Se o militar for promovido, ou enquadrado nas alíneas "b" ou "c" da Tabela II do Anexo IV da Medida Provisória no 2.215-10, de 2001, no período de até um ano após fazer jus ao auxílio-fardamento, ser-lhe-á devida a diferença entre o valor do auxílio referente ao novo posto ou graduação, e o efetivamente recebido.

5. Sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos seguintes termos: (...)

6. Da análise dos autos, tenho que o condicionamento de tempo não pode ser estabelecido em decreto, não sendo uma mera regulamentação, mas uma condição de vantagem, que deve ser prevista em lei. Assim, se a lei não determinou lapso de tempo para o percebimento do auxílio-fardamento, não cabe ao Executivo fixar.

7. Precedente desta Turma Recursal: processo nº 0514084- 94.2017.4.05.8400, relator para o acórdão Almiro José da Rocha Lemos, presentes ainda as juízas Sophia Nóbrega Câmara Lima e Moniky Mayara Costa Fonseca Dantas, sessão de 07/03/2018.

8. Recurso provido para julgar o pedido procedente.

(...)

Assim, pelos fundamentos expostos, não prospera o recurso interposto.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por **NEGAR PROVIMENTO** ao pedido de uniformização, julgando-o como representativo da controvérsia e fixando a tese do Tema 212 nos seguintes termos: "o militar promovido tem direito ao recebimento integral do auxílio-fardamento no valor de um soldo do novo posto ou graduação, mesmo que tenha recebido a mesma vantagem anteriormente dentro do prazo de um ano, sendo ilegal a limitação imposta pelo art. 61 do Decreto nº 4.307/2002".

Ressalto que a 8.^a Turma pacificou o entendimento em relação à matéria ora discutida, entendendo pela procedência do pedido, conforme o julgado no processo nº 5000684-72.2018.4.02.5121. Ocasão, na qual, alterei posicionamento anterior.

Inicialmente, destaco que, anteriormente, o auxílio-fardamento foi previsto na Lei n.º 8.237/91, que especificava as hipóteses de pagamento e estabelecia a possibilidade de redução. Vejamos:

Art. 55. Ao Oficial, Suboficial ou Subtenente e Sargento, ao ser promovido, será concedido um Auxílio-Fardamento correspondente ao valor de dois soldos do novo posto ou graduação.

§ 1º Quando a promoção for ao primeiro posto de Oficial-General, o auxílio a que se refere este artigo será de três vezes o valor do soldo do militar.

§ 2º O auxílio poderá ser renovado a cada quatro anos se o militar permanecer no mesmo posto ou graduação.

§ 3º Ocorrendo a promoção do militar até um ano após o recebimento do auxílio, ser-lhe-á devida a diferença entre o valor do auxílio, referente ao novo posto ou graduação, e o do efetivamente recebido."

Com o advento da MP n.º 2.215/2000, a Lei n.º 8.237 foi revogada, e a MP adotou técnica legislativa diversa. De forma lacônica, o texto da MP apenas consignou a possibilidade de pagamento do auxílio-fardamento - alínea "d", do inciso I do art.2º - como direito remuneratório do militar e estabeleceu no inciso XII do art. 3º da MP 2215-10, que seria pago conforme regulamentação:

"Art. 3º Para os efeitos desta Medida Provisória, entende-se como:

.....

Estabelecendo, contudo, no Anexo IV - Tabela II as situações e os valores de pagamento do auxílio. Vejamos:

ANEXO IV

TABELA II - AUXÍLIO-FARDAMENTO

SITUAÇÕES		VALOR REPRESENTATIVO	FUNDAMENTO
a	O Aspirante, o Cadete, o aluno do Colégio Naval ou das Escolas Preparatórias de Cadetes, o Aluno Gratuito ou Órfão do Colégio Militar e as praças de graduação inferior a Terceiro-Sargento.	Recebem, por conta da União, uniformes, roupa branca e roupa de cama, de acordo com as tabelas de distribuição estabelecidas pelos respectivos Comandos de Força.	Art. 2º e art. 3º, inciso XII.
b	O militar, declarado Guarda-Marinha ou Aspirante a Oficial da Ativa, ou promovido a Terceiro Sargento.	Um soldo e meio.	
c	Os nomeados Oficiais ou Sargentos, ou matriculados em escolas de formação mediante habilitação em concurso e os nomeados Capelães Militares.		
d	O Oficial promovido ao primeiro posto de Oficial General.	Um soldo.	
e	Os Guardas-Marinha e Aspirantes a Oficial, oriundos dos Órgãos de Formação de Oficiais da Reserva, convocados para a prestação do Serviço Militar.		
f	Os médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários, quando convocados para o Serviço Militar Inicial.		
g	O Oficial, Suboficial ou Subtenente e Sargento ao ser promovido.		
h	A cada três anos quando permanecer no mesmo posto ou graduação.		
i	O militar reincluído, convocado ou designado para o serviço ativo.		
j	O militar que retornar à ativa por convocação, designação ou reinclusão, desde que há mais de seis meses de inatividade.		E
l	O militar que perder o uniforme em sinistro ou em caso de calamidade.	Um soldo e meio.	E

Por conseguinte, as hipóteses de pagamento do auxílio-fardamento e o valor devido estão previstos no anexo do MP.

Houve, portanto, inovação em relação à legislação anterior, com o surgimento de hipóteses novas, com a redução do prazo anterior de 4(quatro) anos, para 3 (três) e não houve reprodução da redução de pagamento, que era tradicional.

Outrossim, considerando-se que as hipóteses de pagamento e os respectivos valores devidos estão estabelecidos em ato com força de lei, não pode o decreto, a título de regulamentar, reduzir o previsto na MP, na hipótese.

Ainda que o pagamento reduzido fosse tradição no sistema anterior, pois, a lei assim estabelecia, na atualidade, a lei não previu tal hipótese. E nada impede que alteração legislativa futura a estabeleça para frente.

De forma que, revendo posicionamento anterior, passo a entender que o pagamento da diferença, na hipótese prevista não pode prosperar. Pois, na hipótese específica não foi deferido ao regulamento a possibilidade de regulamentar, o que já foi previsto na MP.

O Decreto neste aspecto e por esse motivo não pode reduzir o que consta na hipótese e na tabela na MP. Muito embora, em outros aspectos a regulamentação possa ser mais ampla.

II - Do caso concreto:

Narra a Autora que, em dezembro de 2016 (evento 1, ANEXO6, fl. 07) e dezembro de 2023 (evento 1, ANEXO6, fl. 09), quando da graduação para 1º Sargento e Suboficial respectivamente, recebeu apenas a diferença do auxílio fardamento entre postos. Entende que deveria ter recebido o valor total do auxílio fardamento referente ao novo posto.

No entanto, o entendimento pacificado nesta Turma é no sentido de que, não se aplica ao auxílio fardamento o mesmo termo inicial do prazo prescricional para as férias.

"[...]"

De plano, no que se refere ao termo inicial da prescrição, vale dizer, que este não ocorre com o auxílio-fardamento, o que se dá, por exemplo, com as férias não gozadas.

Quando a ação versa sobre aquelas, o termo inicial da prescrição é a data em que o militar se inativa. Ocorre dessa forma, porque só se vai saber se aquele tempo foi aproveitado para outros fins, quando a inativação acontece. Por isso, não há inércia antes disso, não havendo que se falar em prescrição.

Todavia, com o auxílio-fardamento, a situação é distinta, porque, se o Recorrente recebe um pagamento que julga ser a menor, o mesmo tem cinco anos para postular o pagamento da diferença, o que não aconteceu nestes autos, no tocante à promoção para Segundo Tenente que se deu em outubro de 2016.

Nesse sentido, fica constatada a ocorrência da prescrição."

No âmbito administrativo, a prescrição ocorre após o decurso do prazo de cinco anos, considerando o disposto artigo 1º do Decreto-Lei n.º 20.910/32.

Portanto, considerando que a ação foi ajuizada em 2024, prescrita tão somente a pretensão autoral quanto ao pagamento realizado em 2016.

A sentença julgou parcial procedente o pedido, reconhecendo tão somente a prescrição quanto ao auxílio pago em 2016, razão pela qual deve ser mantida. Determinando o pagamento quanto a auxílio pago a menor em 2023, não prescrito.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de **CONHECER** e **NEGAR PROVIMENTO** ao recurso. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se. Após, com as cautelas de praxe, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.